

Frieden durch Sicherheit?

Die Kontrolle der Nachrichtendienste aus verfassungsrechtlicher Sicht – am Beispiel der Schweiz

Gabriel Gertsch, BLaw et BIA HSG

Sammeln Nachrichtendienste für präventive Sicherheitsmassnahmen breitgefächert Informationen über gegen die «freiheitliche demokratische Grundordnung» (Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz) gerichtete Aktivitäten, werden regelmässig auch unbescholtene Bürger überwacht. Aktuelle Entwicklungen, wie etwa der systematische Zugriff der NSA auf die globale elektronische Kommunikation, zeigen: die Frage, wie weit Befugnisse der Nachrichtendienste reichen sollen, ist ein drängendes verfassungspolitisches Problem.

Aus Sicht des öffentlichen Rechts bestehen bei der Beantwortung dieser Grundsatzfrage zwar rechtsstaatliche Leitplanken, etwa der Wesensgehalt der Grundrechte. Primär ist die Abwägung zwischen Abwehrrechten und Sicherheit aber durch Verfassungs- und Gesetzgeber zu treffen; es handelt sich insoweit um eine politische Frage. Welchen Beitrag kann dann die Rechtswissenschaft leisten? Das juristische Augenmerk ist m.E. auf Verfahren und institutionelle Vorkehren zu lenken, welche die gesetzes- und grundrechtskonforme Durchführung nachrichtendienstlicher Tätigkeiten kontrollieren.

Dabei darf der Blick nicht ausschliesslich auf eine Rechtmässigkeitskontrolle in Bezug auf die Abwehrrechte überwachter Bürger eingeengt werden. Denn die Schweizerische Bundesverfassung verlangt die «Verwirklichung der Grundrechte» (Art. 35), also auch die Erfüllung staatlicher Schutzpflichten zur Gewährleistung der Sicherheit. Es ist deshalb von einem weiten Kontrollbegriff auszugehen, der auch die Effektivität der Aufgabenerfüllung umfasst.

Dies bedeutet einerseits, dass aus verfassungsrechtlicher Sicht auch ein zu viel an Kontrolle möglich ist; dann nämlich, wenn die Aufgabenerfüllung der Nachrichtendienste unverhältnismässig erschwert wird und dadurch unakzeptable Sicherheitsrisiken entstehen. Andererseits sind neben der klassischen Kontrolle durch die drei Gewalten – verwaltungsinterne Aufsicht, politische Kontrolle durch Parlamente, justizielle Kontrolle im Einzelfall – auch Kontrollinstrumente in einem weiten Sinne zu berücksichtigen: etwa das Trennungsgebot von Polizei- und Staatsschutzbehörden oder das aus dem Legalitätsprinzip fließende Bestimmtheitsgebot.

Die Wirksamkeit einzelner Kontrollinstrumente kann damit erst aus einer Gesamtbetrachtung des gewaltenteiligen Systems von «checks and balances» beurteilt werden. Zwei Beispiele aus dem schweizerischen Aufsichtsregime veranschaulichen dies: (i) Die Kompetenz zur Dienstaufsicht über kantonale Staatsschutzorgane liegt zwar bei der vorgesetzten Stelle des jeweiligen Vollzugsorgans. Allerdings bedürfen deren Einsichtsrechte – aufgrund einer systemwidrigen Einschränkung auf Verordnungsstufe – im Einzelfall der Zustimmung des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB), wodurch ein «blinder Fleck» entsteht. (ii) Mit Art. 190 schliesst die Verfassung eine Verfassungsmässigkeitsprüfung von Bundesgesetzen durch das Bundesgericht aus. Durch diesen Grundentscheid wird einerseits die föderale Machtteilung als institutionelles Kontrollinstrument unterlaufen, da sich die Kantone nicht gegen eine unverfassungsmässige Ausweitung der Bundeskompetenzen wehren können. Andererseits wird dem Bundesgesetzgeber dadurch ermöglicht, bei Beschwerden gegen nachrichtendienstliche Aktivitäten (zu) weitgehende Ausnahmen vom Anspruch auf Zugang zum Gericht vorzusehen.

